

1508261-02.2021.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508261-02.2021.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508261-02.2021.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2220256/2021 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 14076645 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1529/21/110 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1534/21/110 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2220256 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 2 - DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

BRUNO SANTOS DA SILVA e ROBERT CEZAR OLIVEIRA DE AQUINO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incursores, por duas vezes, no artigo 157, §2º,

inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque em 11 de julho de 2021, por volta das 17 horas, na Rua Doutor Fausto Ribeiro de Carvalho, nº 271, bairro Rudge Ramos, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outro indivíduo por ora não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, documentos pessoais, cartões bancários, 02 (dois) capacetes, controle de acesso do portão, 01 (um) telefone celular da marca Asus, 01 (um) molho de chaves, 01 (um) smartwatch, e 02 (duas) jaquetas, de propriedade de Guilherme Xavier Dutra, além de documentos pessoais, cartões bancários, e 01 (um) telefone celular da marca Samsung, de propriedade de Eliane Alves.

Segundo o apurado, BRUNO e ROBERT se ajustaram com outro indivíduo por ora não identificado para a prática de um crime de roubo.

Para tanto, ROBERT assumiu a condução de uma motocicleta, trazendo BRUNO na garupa, ao passo que o indivíduo por ora não identificado ocupou outra moto, trazendo nas costas uma mochila térmica para entrega de comida.

Então, os acusados e seu comparsa trafegavam pela Rua Doutor Fausto Ribeiro de Carvalho, altura do numeral 271, bairro Rudge Ramos, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, quando avistaram Guilherme na condução da motocicleta JTA/Suzuki Vstrom 1000 XT, de placas FQP-7147, e Eliane na garupa.

Os roubadores decidiram abordá-los, mas Guilherme constatou a aproximação das duas motocicletas e, temendo por seu patrimônio e sua integridade física e de sua namorada, alterou o trajeto.

Então, os acusados e o comparsa saíram em disparada no encalço de ambos, até que, alguns quarteirões adiante, efetuaram a abordagem e, mediante porte ostensivo de arma de fogo, exigiram a entrega do veículo, telefones celulares e pertences pessoais. Os ofendidos atenderam à exigência e os roubadores se evadiram do local na condução da moto e na posse dos demais bens subtraídos.

As vítimas registraram os fatos na Delegacia de Polícia e Guilherme conseguiu detectar que o aparelho celular de sua namorada Eliane estava localizado no bairro Vila Clara, em São Paulo - SP.

Em seguida, encontrou em uma rede social a página “vilaclara_oficial” e, dentre fotografias de motos de grande porte, identificou a sua, que foi reconhecida em razão da customização e de algumas avarias. Além disso, Guilherme reconheceu, em fotos, dois dos três autores do crime de roubo.

As fotografias foram entregues à D. Autoridade Policial, que, através do sistema de reconhecimento facial, identificou ROBERT e BRUNO (págs. 25/26).

Os acusados foram prontamente reconhecidos pelas vítimas, que individualizaram a ação de cada um durante a prática delitiva e reconheceram um capacete apreendido na posse de BRUNO como o mesmo utilizado na empreitada criminoso (págs. 33, 36, 93, 95, 97 e 99).

Acompanhada por inquérito policial (págs.05/112), a denúncia foi recebida às págs.121/128, tendo sido decretada a prisão preventiva dos acusados. Os réus foram regularmente citados (pág.259 – Bruno pessoalmente e Robert por edital às págs.238/239). Resposta à acusação às págs.270 e 280/281.

Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs.278/279 e 290/291), em instrução foram ouvidas as vítimas e um testemunha comum, interrogando-se o acusado. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha André L. N. Bolonha. Em memoriais, a acusação requer a condenação do acusado BRUNO nos termos da denúncia, elevando-se a pena e fixando-se o regime inicial fechado para cumprimento. Pediu a absolvição de Robert por insuficiência probatória (págs.306/310).

A defesa de BRUNO postula a absolvição por negativa de autoria ou ainda, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime menos grave de receptação, o afastamento o emprego de arma de fogo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena mínima e de regime mais benéfico, bem como a revogação da prisão preventiva do acusado (págs.343/346).

A defesa de ROBERT requer a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência

probatória (págs.311/312).

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece acolhida. A prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares dos crimes de roubo descritos na denúncia, inexistindo dúvida quanto à autoria de BRUNO.

Em relação ao corréu ROBERT, contudo, a absolvição por insuficiência probatória é a medida escorreita.

A materialidade dos crimes de roubo vem consubstanciada nos autos de exibição e apreensão às págs.91 (capacete de BRUNO, usado no crime, e motocicleta) e de reconhecimento de objeto às págs.33 (indireto - motocicleta roubada) e 96/97 (capacete usado por BRUNO no crime), bem como nos laudos periciais acostados às págs. 252/253 (capacete) e 329/334 (motocicleta) e nas imagens juntadas às págs.29/31.

A condenação do réu BRUNO é a medida escorreita.

Após a opção pelo silêncio na fase policial (pág.83), em Juízo o acusado BRUNO confessou a autoria dos delitos de roubo:

Na data do fato, praticou o crime com os comparsas 'neguinho' e 'alemão', conhecidos da Vila Clara. Usaram duas motocicletas para a prática do delito. Ocupava a garupa da moto de cor azul escuro e usava o capacete apreendido em sua residência pelos policiais. A outra moto era conduzida pelo roubador que trazia uma mochila do Ifood nas costas e portava o simulacro usado para a grave ameaça. Não possuíam arma de fogo. Subtraíram os bens das vítimas nos termos indicados na denúncia, os quais foram vendidos pelos comparsas. Recebeu a quantia de R\$1.800,00. Robert não participou da empreitada criminosa. Trata-se de réu confesso na presença de Magistrada e sob o pálio de todas as garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A confissão, ademais, vem corroborada nas declarações das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório. Guilherme e Eliane narraram os lances do crime de roubo perpetrado três roubadores, mediante emprego de arma de fogo, e espancaram qualquer dúvida acerca da autoria de BRUNO:

Ocupavam a motocicleta JTA/Suzuki Vstrom 1000 XT, de placas FQP-7147. Guilherme era o condutor e Eliane estava na garupa. Guilherme parou em razão de semáforo desfavorável e notou a aproximação das duas motocicletas Honda CG. Uma era ocupada por dois indivíduos. Do outro lado, havia outra moto ocupada por apenas um rapaz com a mochila do ifood nas costas. Eles olhavam para a sua moto e suspeitou que seria roubado, acelerando.

Contudo, Guilherme foi alcançado pelo roubador que portava a mochila do Ifood, o qual exibiu uma arma de fogo às vítimas e determinou que parassem, dizendo-lhes 'perdeu, perdeu'. Guilherme obedeceu ao comando. Em seguida, a moto ocupada pelos outros dois roubadores aproximou-se.

BRUNO, que ocupava a garupa, usando capacete LS2 de cor versa e rosa (as vítimas reconheceram o capacete apreendido na residência de Bruno, cf. auto de reconhecimento de objeto às págs.96 e 97), desceu na moto e passou a ordenar ao comparsa que matasse Guilherme - 'mata ele, que tentou dar fuga' - o que fez por mais de uma vez durante a ação criminosa.

O roubador que tinha a mochila do Ifood nas costas apontou a arma de fogo para a cabeça de Guilherme durante todo o tempo. Os roubadores perguntavam se Guilherme era policial, afirmando que o matariam se fosse.

Além da motocicleta, BRUNO subtraiu capacete, relógio e jaqueta de Guilherme. Os bens de Eliane - jaqueta, capacete, aparelho celular e compras que havia feito no

dia em cidade diversa, além de documentos pessoais - também foram subtraídos pelo condutor da moto que BRUNO ocupava, que a machucou. Durante a ação criminosa, BRUNO e o condutor da moto que ele ocupava tiraram os capacetes que usavam (deixando-os no alto da cabeça, conforme gesticulou a vítima Eliane). Seus rostos ficaram visíveis. Não usavam máscara. Na posse dos bens, os roubadores evadiram-se. Registraram os fatos na Delegacia de Polícia.

O aparelho celular da vítima Eliane estava no baú da moto, ligado e com bateria. Usando sistema de rastreamento (estava sincronizado com o e-mail de Eliane) conseguiram detectar que o bem estava localizado na comunidade Vila Clara, em São Paulo - SP.

Efetuaram pesquisa e, aproximadamente três dias depois do roubo, amigo os auxiliou a encontrar na rede social a página "vilaclara_oficial" (região indicada no GPS do aparelho celular de Eliane). Dentre fotografias de motos de grande porte exibidas, Guilherme identificou a sua, reconhecida em razão da customização (pedaleira com ferradura e ferros laterais instalados para carregar bagagens, acompanhado de corrente de cabo de aço para amarrar capacetes) e de algumas avarias (lado superior do para-brisa trincado, farol de milha auxiliar descascado e queimado). Guilherme e Eliane também reconheceram BRUNO na fotografia de pág.30 (sentado na moto subtraída da vítima). Ele usava o mesmo capacete que vestia na data do crime. As fotografias foram entregues à D. Autoridade Policial, formalizando-se o auto de reconhecimento fotográfico (pág.36). Por meio do sistema de reconhecimento facial, a Polícia Civil identificou e qualificou o réu BRUNO (págs. 25/26). O acusado BRUNO foi pronta e pessoalmente reconhecido pelas vítimas na Delegacia de Polícia (cf. auto de reconhecimento pessoal positivo às págs.93 e 99), que individualizaram a sua ação e reconheceram um capacete apreendido na casa do acusado, apontando-o com o mesmo utilizado na empreitada criminosa (cf. autos de reconhecimento de objeto às págs.96 e 97).

Os bens subtraídos não foram recuperados. Ratificando a reconhecimento anterior (págs.93 e 99), em Juízo as vítimas reconheceram o réu BRUNO sem esboço de dúvida (para garantir a credibilidade do ato, o réu foi colocado ao lado de outros presos recolhidos no Centro de Detenção Provisória. Para a vítima Guilherme, o acusado foi exibido ostentando a placa nº 02. No positivo reconhecimento efetuado por Eliane, Bruno usava a placa nº 03).

Nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de roubo, as declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, possuem relevante valor probatório.

Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] "Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço". [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019). Não se olvida a alegação defensiva de que o reconhecimento do acusado foi efetuado,

NA DELEGACIA DE POLÍCIA, sem as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

O procedimento previsto no inciso II, do mencionado dispositivo legal, não é obrigatório. A determinação de colocação da pessoa, cuja identificação se pretende, ao lado de outras que com ela tiverem alguma semelhança, vem acompanhada da locução "se possível", o que se traduz em mera recomendação.

Com pena de mestre, o escólio de Vicente Greco Filho pontua:

"Há dois tipos de reconhecimento de pessoas ou coisas. O informal, que, na prática, se realiza na própria audiência de testemunhas, quando o juiz pergunta, por exemplo, em audiência se a testemunha reconhece o réu ou a arma do crime. Esse reconhecimento é confirmatório porque somente complementa o depoimento ou a declaração. Havendo necessidade de assegurar ao reconhecimento maior certeza e, especialmente, se houver dúvida a respeito da identificação de pessoa ou coisa, deve ser feito o reconhecimento formal previsto nos arts. 226 a 228 do Código" (in Manual de Processo Penal, Ed. Saraiva, 4ª ed., 1997, p. 236).

Também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS EM JUÍZO. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DE TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE.

AUSÊNCIA.PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A inobservância da forma estabelecida no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas e coisas não produz nulidade absoluta, máxime quando se tratar de confirmação de reconhecimento já realizado na fase inquisitorial". (STJ Sexta Turma; HC 397523/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 05.04.2018, DJe 16.04.2018)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO REALIZADO NA FASE POLICIAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE PROVA SEGURA PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO.

INVIABILIDADE DE EXAME NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PODER

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 15ª CÂMARA DE DIREITO

CRIMINAL Apelação Criminal Nº 0000995-19.2017.8.26.0066 - COMARCA: Barretos - VOTO Nº 10 IMPROVIDO. 1. "Ainda que não observado totalmente o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não há se falar em nulidade, haja vista não se ter demonstrado eventual prejuízo, o qual nem ao menos se pode presumir, diante da existência de outras provas da autoria, devidamente judicializadas" (AgRg no REsp 1063031/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 27/02/2012). 2. No caso, embora na fase policial o paciente tenha sido reconhecido de forma isolada, sem confronto com outras pessoas, o reconhecimento deu-se de forma segura e, posteriormente, foi confirmado em Juízo, o que afasta o apontado constrangimento ilegal". (STJ Sexta Turma; AgRg no HC 381074/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.04.2018, DJe 02.04.2018).

Destaca-se que, em Juízo, o acusado foi colocado ao lado de outros presos semelhantes, não tendo, as vítimas, dúvida em apontá-lo como o autor do crime.

Não há amparo em adminículo de prova a alegação defensiva de que a vítima foi induzida pelo positivo reconhecimento efetuado na fase policial.

No mais, o reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas na fase policial vem ratificado nas declarações que prestaram em Juízo e amparado na confissão judicial do acusado, ofertada espontaneamente e sob o pálio das garantias constitucionais. Os dizeres das vítimas foram corroborados pelo depoimento do policial civil Cesar Augusto M. Aprile, que em relato coeso e harmônico com o anterior, informou em Juízo os passos da diligência encetada na data dos fatos e confirmou a autoria: Noticiado o crime, as vítimas indicaram o local apontado pelo GPS do aparelho celular subtraído de Eliane. Tratava-se da comunidade da Vila Clara/SP, local conhecido pela ocorrência de bailes funk e circulação de motocicletas roubadas. A comunidade tem página oficial em rede social. Ali são postadas fotografias de indivíduos em motos, inclusive as de origem ilícita.

A vítima Guilherme visualizou BRUNO sentado na motocicleta dela subtraída, reconhecendo-o como um dos autores do crime. A qualificação de BRUNO foi obtida no

sistema AFIS.

Expedido mandado de busca e apreensão e decretada a prisão temporária de BRUNO (medidas judicialmente deferidas no apenso nº1508133-79.2021), na casa de BRUNO foi apreendido o capacete usado por ele no crime (reconhecido pelas vítimas às págs.96/97) e cumprido o mandado de prisão.

O aparelho celular de Bruno também foi apreendido, sendo que na foto de fundo era possível visualizar a motocicleta subtraída na data do fato.

Inquirido, BRUNO admitiu a prática do delito, confirmou que a moto visualizada na fotografia de pág.30 era a roubada na data do crime e informou que a moto havia sido vendida pelo valor de R\$.3800,00. No mercado, a moto vale R\$54.000,00.

Na Delegacia de Polícia, BRUNO foi exibido e reconhecido pessoalmente pelas vítimas.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado (STF-HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996- p. 39.846).

E seus informes devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas. Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade da testemunha, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Configuradas as causas de aumento de pena previstas no inciso II do §2º, e inciso I do §2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal.

O emprego de arma de fogo para o exercício da grave ameaça vem demonstrado nas firmes declarações das vítimas, que visualizaram o instrumento exibido por um dos roubadores para a subtração de seus bens.

Não se olvida que a arma empregada não foi apreendida. Todavia, constitui entendimento da jurisprudência que, se a palavra da vítima pode o mais - identificar o roubo - seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de arma de fogo.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"(...) A Terceira Seção pacificou o entendimento no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para que seja configurada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, I, do Código Penal, desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua utilização na prática do delito. Ressalva de entendimento da relatora (...)" (HC 395056/SP, Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. em 05.09.2017, DJe 18.09.2017).

Ademais, entre a prática do roubo e a prisão do acusado decorreu tempo suficiente para que BRUNO e comparsas a dispensassem.

A ausência de exame pericial para a demonstração da capacidade ofensiva do instrumento, uma vez reconhecido o seu emprego na execução do crime, não afeta o reconhecimento da causa de aumento. A comprovação da ausência de eficácia lesiva da arma era ônus do réu, do qual não se desincumbiu a contento (CPP, art.156).

A comparsaria entre o réu BRUNO e outros dois roubadores não identificados ficou provada pelo modo como os agentes atuaram, em conjunto e com plena aderência de vontades. A par da divisão de tarefas relatada pelas vítimas desde o início da ação criminosa, cada qual fez sua a ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo.

O delito de roubo consumou-se.

Este Juízo adota o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração com emprego de violência ou grave ameaça, invertendo-se a posse, justamente o que se viu patenteado na hipótese dos autos.

A propósito:

"O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Não é preciso que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se

transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-lo pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do esforço imediato – seria ato de turbção (ameaça) à posse do ladrão” (Rel. Min. MOREIRA ALVES – RT 677/428).

Visando uniformizar o entendimento acima exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a recente Súmula nº 582, com o seguinte teor:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Na hipótese dos autos, os bens subtraídos sequer foram recuperados.

Finalmente, ficou provado que o réu, mediante única ação, atingiu, ciente de tal fato (conforme dinâmica relatada pelas vítimas), dolosamente, o patrimônio de duas vítimas diferentes (documentos pessoais, cartões bancários, 02 (dois) capacetes, controle de acesso do portão, 01 (um) telefone celular da marca Asus, 01 (um) molho de chaves, 01 (um) smartwatch, e 02 (duas) jaquetas, de propriedade de Guilherme Xavier Dutra, e documentos pessoais, cartões bancários, e 01 (um) telefone celular da marca Samsung, de propriedade de Eliane Alves. Eliane vestia a jaqueta e o capacete de Guilherme).

Portanto, incide a regra do concurso formal de crimes, prevista no artigo 70, caput, do Código Penal.

É a posição pacífica de nossos Tribunais:

“Roubos praticados contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático, mediante uma única ação desdobrada em vários atos, constituem concurso formal de crimes e não crime único” (TJSP-Ver.-Rel. Bittencourt Rodrigues j.19.08.1997 RT750/606).

“Concurso formal de delitos Se, durante uma investida de um trio de roubadores, duas vítimas foram imobilizadas sob grave ameaça a mão armada e, por isso, tiveram os respectivos patrimônios desfalcados, houve concurso formal de delitos e não crime único”(TACRIM-SP-AC-Rel. Haroldo Luz JUTACRIM 99/76).

Finalmente, não se olvida a justificativa ofertada pelo acusado BRUNO para a prática do delito: Dificuldade financeira.

Ocorre que tal circunstância, por si só, não configura estado de necessidade.

Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida. De tal ônus o réu não se desincumbiu a contento.

Inexiste nos autos prova da situação de extrema necessidade do acusado, de que agiu visando proteger-se de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa, elementos mínimos necessários para acolhimento da excludente de ilicitude/antijuridicidade.

Nessa linha:

“(…) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava “desesperado”, pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(…)” (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

“(…) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como

justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa.

Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos delitos de roubo pelo acusado BRUNO.

Presentes as elementares do crime de roubo – na confissão judicial do agente, nas declarações das vítimas e do policial civil e nas imagens juntadas aos autos – não merece guarida o pedido defensivo para a desclassificação da conduta para a menos grave prevista no artigo 180 do Código Penal (de receptação).

De outra parte, melhor sorte não assiste à acusação em relação ao réu ROBERT.

Em Juízo, ROBERT negou a prática do delito. Disse que, na data do fato, estava na residência do avô, em Capão Bonito/SP. Passou a morar no local para auxiliá-lo. É padrinho de um dos filhos do corréu Bruno e por isso aparece em fotografia ao lado dele, em rede social.

Se de um lado a negativa de autoria não foi de todo convincente, de outro a prova dos autos não permitiram esclarecimento confiável acerca da participação do acusado no fato em apreço.

Com efeito, embora as vítimas tenham apontado semelhanças entre ROBERT e o condutor da motocicleta que o réu BRUNO ocupava na ação criminosa, há contradições que despertaram dúvida no espírito da julgadora.

Com efeito, ROBERT não tem a cor da pele indicada pela vítima Eliane em Juízo e tampouco ostenta tatuagem no pescoço nos moldes afirmados pelo ofendido Guilherme. O 'olho caído' que teria levado ao reconhecimento de Eliane em Juízo (Guilherme não o reconheceu na audiência de instrução, debates e julgamento), por si só, não é suficiente para o édito condenatório.

Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público no memoriais (pág.309):

“Além disso, observa-se que ROBERT foi identificado como um dos assaltantes durante a investigação porque naquela página do instagram há apenas uma fotografia em que ele está junto com BRUNO.

Não há em relação a ROBERT, no entanto, nenhuma imagem dele em poder dos bens subtraídos, na posse de motocicletas de alta cilindrada ou com as mesmas vestimentas utilizadas no assalto, de modo que, diferentemente da situação de BRUNO, seu quadro probatório é frágil.

E, na dúvida, para evitar uma condenação injusta, a melhor solução é a absolvição". Há FORTES indícios, não se olvida, de autoria. Todavia, é perfilhado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os indícios autorizam a condenação se houver o concurso das condições seguintes: a) que os elementos materiais do crime estejam plenamente provados; b) que, em recíproco apoio por prova inequívoca e concludente, incriminem o acusado, importando a exclusão de qualquer hipótese favorável a este (RT 169/76), o que não ocorre plenamente na hipótese dos autos.

Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, a participação do acusado no fato que lhe é imputado na denúncia.

Assim, a absolvição por insuficiência probatória é de rigor.

Dessarte, o réu BRUNO realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado.

Maior a censurabilidade da conduta do agente em razão do bem roubado. Motocicletas de alta cilindrada são objetos de considerável valor. Na hipótese dos autos, foi apontado o valor de R\$54.000,00.

São alarmantes os índices de furto e roubo de tal espécie de veículo, que causam elevação de seguros, estimulam desmanches e mercado paralelo de compra e venda de peças retiradas dos carros subtraídos.

Exige-se séria e enérgica repressão estatal, sob pena de se chegar a uma situação de absoluta desestruturação do convívio em sociedade. Pena mais severa é necessária para desestimular tal prática, tão lucrativa para os criminosos.

Outrossim, além de ser um delito que pelo valor do objeto produto de crime gera maiores vantagens ao criminoso, em contrapartida a consequências mais danosas à vítima, é inegável ser maior a determinação criminosa, pois a motocicleta está sujeita a diversos controles públicos de propriedade e circulação, o que não ocorre com um objeto pequeno, de baixo valor e de fácil ocultação e comercialização. Por tal razão, fere o princípio da individualização da pena apenas igualmente a subtração de uma motocicleta de 1000 cilindradas a de um aparelho celular ou relógio. As gravidades das condutas são díspares, denotando no caso do crime relativo a veículos culpabilidade redobrada e personalidade mais seriamente comprometida e voltada para a criminalidade.

O policial civil informou, ainda, que motos dessa espécie são subtraídas para ostentação em baile funk da Vila Clara. E, na hipótese dos autos, o acusado passou a postar fotografias na moto roubada em rede social oficial da Comunidade Vila Clara, conforme imagens juntadas aos autos, o que torna a sua conduta mais censurável.

Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, elevando-a em 1/8, o que perfaz 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa para cada crime de roubo. Não incidem agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena de BRUNO ao patamar mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira etapa da dosimetria, presentes duas causas especiais de aumento de pena: A referente ao concurso de agentes, que enseja acréscimo de um terço, e a tocante ao emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal - alterado pela Lei nº 13.654/18), que autoriza aumento de dois terços.

O aumento mínimo não atende as finalidades da sanção penal.

Um roubo cometido com uma causa de aumento não é igual a outro praticado com duas ou mais majorantes, sendo que nesta última situação o acusado deve ser apenado com mais rigor, sob pena de inobservância do princípio isonômico e da mais adequada individualização da pena em cada caso concreto.

É maior a reprovabilidade da conduta do agente na segunda hipótese, justamente o que se vê patenteado nestes autos.

Na concorrência das causas de aumento, incide o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se a fração maior, de dois terços (TJSP - Apelação Criminal 0046845-13.2018.8.26.0050; Relator (a): Xavier de Souza; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).

O legislador, de forma consciente da necessidade de se adotar uma resposta penal adequada a garantir a proteção penal ao bem jurídico tutelado nos crimes de roubo com emprego de arma de fogo (com potencial risco à integridade física e à vida da vítima), imprimiu maior rigidez ao punir o agente que se utiliza de tal instrumento lesivo, decorrendo tal prerrogativa de política pública que não pode ser indevidamente afastada pelo Judiciário.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade diante da aplicação

do índice de 2/3.

Conforme já decidiu o E. TJ/SP:

"(...) De início, ressalto que o órgão fracionado pode, sem ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Carta Magna, rejeitar a arguição de inconstitucionalidade. Primeiro porque todas as leis gozam de presunção de constitucionalidade, não sendo necessária declaração formal para tanto e tampouco submissão ao Órgão Especial. Segundo porque assim dispõe o Código de Processo Civil ao tratar do incidente de arguição de inconstitucionalidade nos Tribunais. Com efeito, o referido código dispõe que arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator submeterá o feito à câmara que competir o conhecimento do processo e, rejeitada tal arguição, prosseguirá o julgamento (art. 949, I do CPC). Dito isto, anoto que a Lei nº 13.654, de 2018, a qual revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal e incluiu ao dispositivo o §2º-A, dispondo que a pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo (inciso I), encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal. Afinal, o delito de roubo é um crime complexo que atinge não só o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa, mormente se praticado mediante o emprego de arma de fogo. Assim, porque ofende mais um de bem jurídico e porque, em última análise, trata de proteção à vida, o aumento de pena para o caso de emprego de arma de fogo, antes de contrariar o princípio da proporcionalidade, a ele se adequa, na medida em que ajusta a proteção antes insuficiente conferida pelo Direito Penal ao bem jurídico da mais elevada importância, no caso a vida." (TJ/SP; Apelação Criminal nº 0000961-52.2018.8.26.0537; Relator(a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2019).

Na mesma linha: TJ/SP, Apelação nº 0046228-53.2018.8.26.0050, 16ª Câmara Criminal, Rel. Desembargador Newton Neves, julgado em 31.10.2018.

Assim, as penas do acusado ficam estabelecidas em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, para cada crime.

Reconhecido o concurso formal de crimes (praticados dois delitos de roubo), elevo a pena de um deles, pois idênticas, em 1/6, fixando-a definitivamente em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 32 dias-multa (CP, art.72).

Nesta linha:

"A PENA APLICADA HÁ DE SOFRER MAJORAÇÃO COM O ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DELITOS, NECESSÁRIA À REPREENSÃO E REPROVAÇÃO PELA EXTENSÃO DOS DANOS DECORRENTES DA CONDUTA APELAÇÃO. (...) - No concurso formal, o número de infrações é que determina o aumento da pena. A existência de duas vítimas autoriza o aumento no mínimo (um sexto), enquanto a presença de sete ou mais o eleva para o máximo, metade" (TJDF 20010510057180APR, Relator EVERARDS MOTA E MATOS, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/11/2002, DJ 26/02/2003 p. 65 sem grifos no original).

Não há causa de diminuição de pena.

O valor de cada dia-multa, ante a aparente precariedade da situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo e será atualizado nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338). Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado. É o que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito e as circunstâncias nas quais foi praticado, que bem demonstram a sua ousadia e periculosidade, reclamando reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumprе salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a prática do delito nos moldes apurados nos autos (em duas motos e com superioridade numérica; com emprego de arma de fogo; com constantes ameaças de morte dirigidas à vítima Guilherme – BRUNO ordenava ao comparsa que matasse o ofendido, pois inicialmente tinha fugido da ação criminosa e agindo na frente de diversas pessoas, conforme informado pela vítima Eliane, sem que a circunstância o intimidasse. A audácia do

acusado durante a ação criminosa não foi suficiente. BRUNO passou a publicar fotografias sentado na motocicleta roubada da vítima em rede social oficial), denota periculosidade acentuada, personalidade e conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade, sujeitando o agente à modalidade fechada.

Evidentemente, as circunstâncias do delito e suas desfavoráveis condições subjetivas apontam que a fixação do regime semiaberto ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes requisitos objetivos e subjetivos, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração da conduta.

Não são medidas socialmente recomendáveis e não atenderiam às finalidades da sanção penal (prevenção e repressão).

Não se olvida, finalmente, que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal para permitir a(o) Juiz(iza) o desconto, na sentença, do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta.

Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado na hipótese vertente.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade da conduta do agente nos moldes apontados para elevação da pena base e fixação do regime fechado, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal.

No caso em tela, conforme demonstrado, há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa. Outrossim, não há certeza que a pena ora aplicada será a definitiva, eis que é passível, ainda, de recurso por parte do Ministério Público, o que poderá modificar o cálculo para a eventual progressão. Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

"Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP 5ª Câmara Criminal – Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para:

a) declarar o réu BRUNO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e §2º-A, inciso I (arma de fogo), c.c artigo 70, caput (por duas vezes), todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 32 dias-multa (CP, art.72), no valor unitário mínimo.

b) ABSOLVER o réu ROBERT CEZAR OLIVEIRA DE AQUINO, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e §2º-A, inciso I (arma de fogo), c.c artigo 70, caput (por duas vezes), todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelas razões expostas alhures.

O réu BRUNO respondeu ao processo preso, decretada a prisão preventiva às págs.121/128. Permanecem os requisitos legais da custódia cautelar, destinada à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

O delito de roubo tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. O fumus commissi delicti vem consubstanciado nas declarações das vítimas, no depoimento do policial civil, na confissão judicial do acusado e na presente condenação.

O periculum libertatis está demonstrado na gravidade CONCRETA da conduta praticada pelo acusado e na conduta social não consoante ao convívio em liberdade.

BRUNO agiu com emprego de arma de fogo e em comparsaria com outros dois indivíduos, usando duas motos – uma delas disfarçada de entrega do Ifood – para abordagem da vítima. Durante a ação criminosa, BRUNO ordenava ao comparsa que matasse o ofendido, pois Guilherme inicialmente tinha fugido da ação criminosa. A vítima Eliane afirmou que o acusado e comparsas não se intimidaram quando moradores passaram a filmar a ação criminosa ou quando um veículo se aproximou, prosseguindo na execução do crime. A audácia do acusado durante a ação criminosa não foi suficiente. BRUNO passou a publicar fotografias sentado na motocicleta roubada da vítima em rede social oficial – instagram – de comunidade conhecida pela prática de baile funk, onde motos de alta cilindradas roubadas são ostentadas.

Necessário acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

As medidas cautelares previstas na legislação processual não teriam idêntico efeito garantidor da prisão preventiva, pois não suficientes e adequadas às circunstâncias do crime e condições subjetivas do acusado, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar para atendimento das finalidades da persecução penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o acusado na prisão onde se encontra recolhido. Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em relação ao réu ROBERT, o contramandado de prisão foi expedido a pág.315, revogada a prisão preventiva do acusado. Absolvido e solto, sem novos percalços, poderá apelar em liberdade.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Sobre os bens apreendidos e periciados, observe-se:

a) A motocicleta apreendida em poder do acusado BRUNO foi restituída (pág.315);
b) Se no prazo de 30 dias da intimação do acusado BRUNO, não forem reclamados nos autos o capacete e aparelho celular, mediante devida comprovação da propriedade nos autos, ficam automaticamente perdidos em favor da União. Considerando-se reduzido e insuficiente o valor de tais bens para cobrir o custo gerado por eventual leilão realizado pelo Poder Público, deve ser encaminhado ofício à Autoridade competente para destruição, após certidão nos autos.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu BRUNO no rol dos culpados, expedindo-se guia de execução definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento.

Custas pelo réu BRUNO, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei nº. 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C

São Bernardo do Campo, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA